

1502305-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... penais análogas, como o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Assim, impõe-se ao Judiciário a adequação da pena cominada ao crime em tela, inclusive porque já fruto de arguição de inconstitucionalidade neste Tribunal, que entendeu inconstitucional o preceito secundário do artigo sob exame: "Arguição de inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade do preceito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº:1502305-09.2022.8.26.0228 - C. 2022/000154 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502305-09.2022.8.26.0228 - C. 2022/000154

Réu:

JOAO MARCIO SOUZA CRUZ OLIVEIRA

Aos 22 de março de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes. Aberta, com as formalidades legais, observou-se no lobby da sala virtual, tendo se verificado a exitosa conexão da representante do Ministério Público, na pessoa da Dra. CLÁUDIA PORRO, presente o réu JOAO MARCIO SOUZA CRUZ OLIVEIRA, qualificado em apartado, a defesa na pessoa do Dr. CARLOS HENRIQUE CIRINO BARBOSA JÚNIOR, OAB/SP 388.299, e as testemunhas de acusação HEBERT ROGER DE ALMEIDA, DANIEL PRESUTTI, WESLEY AMARAL TREVIZAM, bem como a testemunha comum GUILHERME AUGUSTO SILVA RODRIGUES, e as testemunhas de Defesa CAIQUE MEIRELLES, EDER DA SILVA NASCIMENTO E VINICIUS CARDOSO RAIMUNDO. Antes de iniciados os trabalhos, com relação à resposta à acusação de fls. 150/156, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito. Pelo MM. Juiz foi dito: Não sendo caso de absolvição sumária, mantenho o recebimento da denúncia, por seus próprios fundamentos. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz, foi dito: posto que frustrada sua citação pessoal anterior, pelo presente, dou o acusado citado da ação penal em curso. Após, pela Defesa, foi dito que dispensava a oitiva das testemunhas arroladas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas de acusação e comum e, em seguida, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos

termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais. Sem prejuízo, atento ao que bem requereu o denunciado, nesta audiência, nos termos da Lei nº 1060/50, a ele concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, pela mesma foi dito: JOÃO MARCIO SOUZA CRUZ OLIVEIRA foi denunciado por infração ao art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, porque que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta 13h40, à Rua Minas de Santa Fé, nº 40, Iguatemi, nesta capital, tinha em depósito para a venda 05 frascos contendo Durateston; 02 frascos contendo Trembolona; 04 frascos contendo Propionato; 02 frascos contendo Deca; 04 frascos contendo Anantato; 03 frascos contendo Masteron; 01 frasco contendo Dianabol; 02 frascos contendo Boldenona; 02 frascos contendo Primobolan; 01 frasco contendo Hemogenin; 03 frascos contendo Cut-Stack; 05 frascos contendo Potenay; 02 frascos contendo Decanoate; 02 frascos contendo Cypionate; 01 frasco contendo Sustanon; e 04 frascos contendo Enanthate, produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Segundo o apurado, na data supramencionada, policiais civis, após receberam informações anônimas, dirigiram-se ao endereço dos fatos. No local, encontraram o estabelecimento "Academia Boa Forma", sendo recepcionados pelo funcionário Guilherme. De imediato, verificaram uma bolsa na recepção contendo cinco frascos de Potenay (uso veterinário injetável), dois frascos de Nandrolona - Deca 200, dois frascos de Durateston 250, um frasco de Enantato de Trembolona - Trembo 200 e um frasco de Masteron 100. Indagado sobre as substâncias, o funcionário respondeu não saber quem seria o proprietário. Ato contínuo, após ser questionado sobre o responsável pelo estabelecimento, o funcionário Guilherme indicou que este estaria na parte dos fundos do imóvel. Dirigindo-se até o local, os policiais identificaram JOÃO MARCIO. Com denunciado foram encontrados os demais frascos contendo substâncias anabólicas. Informalmente, o acusado confessou aos policiais que é dono do estabelecimento e vende as substâncias para amigos e alguns clientes da academia. Diante das circunstâncias, JOÃO MARCIO foi preso em flagrante delito. As substâncias foram devidamente apreendidas (fls. 12/14). Em sede policial, ao ser interrogado, o denunciado exerceu seu direito de permanecer silente (fls. 18). Devidamente citado, apresentou resposta escrita. Ao longo da instrução foram ouvidas quatro testemunhas arroladas na denúncia, procedendo-se ao interrogatório. O réu manteve-se em silêncio na fase policial. Perante o Juízo o réu disse que guardava as substâncias para uso próprio para um protocolo de seis meses por fazer fisioculturismo. O Policial Civil Roger reconheceu o réu em audiência e narrou ter recebido denúncia anônima, em razão de outra prisão, e era no sentido de que a academia que JOÃO era dono o uso de anabolizantes era normal. Fizeram campana na porta e em certo momento ingressaram na academia e informaram acerca da denúncia sobre o uso de anabolizantes. O funcionário disse que niguem fazia uso. Havia um bolsa com seringas nas laterais e viu que tinha potinhos de substâncias de uso veterinário dentre outros. Indagado de quem era, ele negou a propriedade. Indagado quem era o instrutor responsável, disse que era no fundo. Foi ao fundo e viu etiquetas de insumos e pote de semente de uva. Identificou-se com o Policial e o réu negou que fosse dele. Ele disse que era dono da semente de uva e levou-os a uma caixa com outros produtos, que tinha produtos igual a receptação da academia. Ele disse que as substâncias eram dele e passava para colegas "body builders". No mesmo sentido, o Policial Civil Daniel declarou que receberam notícia informal de que a academia vendia anabolizantes e o pessoal consumia lá. Foram ao local, ficaram na porta e em certo momento entraram. Foram atendidos por Guilherme que era o recepcionista e identificaram-se. Guilherme permitiu que olhassem. No balcão que tinha atrás tinha uma bolsinha com seringas e haviam vários frascos de anabolizantes. Indagado ele disse que não era dele e informou que o proprietário do estabelecimento estava no fundo. Encontraram o réu lá no fundo mas viram uma caixa de papelão com rolos de etiquetas para colocar nos frascos. Indagado ele disse que era dele e permitiu que olhasse o restante. Na cozinha tinha vários, assim como nas gavetas e na sala. Havia diversos tipos de substâncias e ele admitiu que era dele e vendia para alguns amigos e alunos. O Policial Civil Wesley

também reconheceu o réu e narrou que na data dos fatos estava com o pé ruim e levaram Daniel para prestar apoio e ficou do lado de fora da academia e não conseguiu subir a escada. No local foram apreendidas algumas substâncias anabolizantes. A denúncia veio através de um flagrante anterior e ele disse informalmente que comprava através dessa academia. A testemunha Guilherme disse que trabalha na Academia Boa Forma como recepcionista e estava no local quando chegaram os Policiais Civis que apreenderam diversas substâncias. Não sabe de quem era a bolsa. Um aluno se identificou dizendo que a bolsa era dele e tinha o R.G.. dele. O proprietário da Academia é o réu que dá aula de musculação. Já fez uso de anabolizantes. Ele não vende anabolizantes e participa de campeonatos. Os Policiais foram direto à recepção. Não sabe dizer porque não falou para a Delegacia que o dono da bolsa apareceu. O aluno Weber se apresentou como dono da bolsa. Das provas coligidas, não restam dúvidas em razão mesmo da notícia anônima que chegou aos Policiais Civis e que ensejou a abordagem, assim como em razão da grande quantidade de substâncias apreendidas não restam dúvidas que o réu guardava e tinha em depósito também para o consumo de terceiros. Não é formado em Educação Física. Ante todo o exposto, aguarda a Promotoria de Justiça seja a presente ação penal julgada inteiramente PROCEDENTE CONDENANDO-SE o réu nos exatos termos da denúncia. Na dosagem da pena aguarda-se a consideração da grande e diversidade de substâncias apreendidas.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, ofereço debates oralmente.

Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: Vistos. JOÃO MÁRCIO SOUZA CRUZ OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 13hs40min, na rua Minas de Santa Fé, 40, Iguatemi, nesta capital, tinha em depósito para a venda os produtos e substâncias listados na inicial acusatória, sem o necessário registro no órgão competente de vigilância sanitária. Consoante apurado, na data dos fatos, policiais civis, após receberem informações anônimas, se dirigiram ao endereço indicado, o estabelecimento "Academia Boa Forma", sendo recepcionados pelo funcionário Guilherme. De imediato, verificaram uma bolsa na recepção contendo diversos frascos dos produtos indicados na denúncia. Indagado, sobre as substâncias, respondeu não saber quem seria o proprietário, indicando o acusado como o responsável pelo estabelecimento. Assim foi que localizado na parte dos fundos do imóvel, com o denunciado foram encontrados mais frascos contendo substâncias anabólicas. Recebida a denúncia, citado, apresentou defesa preliminar. Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas de acusação e comuns, afinal interrogado o réu. Em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva. A Defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, para tanto apontou a fragilidade do conjunto probatório; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. É o relatório. Decido. A ação penal é parcialmente procedente. Com efeito, finda a instrução criminal, a materialidade restou fartamente comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 2/5, 6/8, autos de exibição e apreensão (fls. 12/14, 15/16), bem como pelo laudo pericial de fls. 164/167. Igualmente, a autoria é incontestada, não só pelo teor das provas colhidas na fase inquisitiva, mormente pelas investigações policiais derivadas da denúncia anônima inicial, quanto pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, em tudo demonstrando a venda/comércio ilícito de produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Também não há que se falar em ofensa ao princípio da ofensividade, que exigiria da conduta, concretamente, lesão ou risco ao bem jurídico. De fato, tratando-se de crime de perigo abstrato, é plenamente dispensável que tenha ocorrido dano concreto à saúde de eventuais usuários das substâncias, bastando a prática de uma das condutas descritas no artigo 273, do CP, pois o legislador estabeleceu uma presunção legal absoluta de perigo para a saúde pública. Neste sentido, Nucci explica que "não há qualquer inconstitucionalidade em admitir o perigo abstrato, que é fruto da

experiência auferida pelo legislador, passada à elaboração do tipo penal, prerrogativa sua e não do Poder Judiciário. Foge assim e dever-se-ia exigir, igualmente, perigo concreto de todas as infrações de perigo, pois, se a presunção não pode ser válida para um determinado tipo incriminador, também não deve sê-lo para os demais" (in Código Penal Comentado, 11ª Ed., pg. 1062). Tampouco deve ser acolhido pleito de desclassificação para a modalidade culposa do crime. Além do mais, pouco importa se os produtos eram autênticos. Tratando-se de crime de perigo abstrato, a lesão ou o risco de lesão são igualmente presumidos. Assim, devidamente demonstradas a autoria e materialidade delitiva e não prosperando as teses defensivas em quaisquer de seus outros aspectos, de rigor a condenação do réu pelo crime pelo qual denunciado. Por fim, com relação à alegação da inconstitucionalidade do artigo 273, do CP, primeiramente, não se pode perder de vista que o legislador, ao editar a Lei nº 9.677/98, estabeleceu relevantes modificações ao referido dispositivo ao introduzir novos núcleos de tipificação do crime, a fim de impor maior controle à venda de medicamentos, tendo em vista a proteção da saúde pública. Ocorre que a pena mínima de 10 anos imposta pelo legislador mostra-se flagrantemente desproporcional, ainda mais considerando que se trata de crimes de perigo abstrato e, ainda levando-se em conta figuras penais análogas, como o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Assim, impõe-se ao Judiciário a adequação da pena cominada ao crime em tela, inclusive porque já fruto de arguição de inconstitucionalidade neste Tribunal, que entendeu inconstitucional o preceito secundário do artigo sob exame: "Arguição de inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal. Conhecimento. Morte do interessado no curso da revisão criminal que não leva à sua extinção. Inteligência do art. 631 do Código de Processo Penal. Verificação da desproporcionalidade do preceito secundário do dispositivo impugnado, especialmente se comparado a delitos semelhantes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Arguição julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da pena do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal" (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0052451-46.2016.8.26.0000, Rel. designado Des. Márcio Bartoli, j. 28.6.2017). No mesmo sentido, concluiu a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Arguição de inconstitucionalidade. Preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP. Crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Ofensa ao princípio da proporcionalidade. A intervenção estatal por meio do Direito Penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. Em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretense usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. Arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma" (AI no HC 239.363, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,

j. 26.02.2015). Conquanto este julgado trate apenas do inciso V, do referido dispositivo legal, percebe-se que o acórdão se referiu ao tema de forma genérica. Dessa forma, conforme exposto acima, na esteira do entendimento desta E. Corte e do Colendo STF, ao declararem a inconstitucionalidade da pena (preceito secundário) do artigo 273, § 1º-B, adoto, em sua substituição, a reprimenda prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, reclusão de 05 a 15 anos e pagamento de 500 e 1500 dias-multa, até porque ambos os delitos têm por escopo a tutela da saúde pública e merecem o mesmo juízo de reprovabilidade. Passo a dosar a pena. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, culpabilidade normal à espécie, personalidade, primariedade, circunstâncias e consequências delitivas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, observo que não incide à reprimenda anteriormente fixada qualquer outra causa de aumento, entretanto, deve ser observada a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Diante disso, atento as condições e circunstâncias subjetivas e objetivas acima indicadas, em especial, ao montante de produtos apreendidos, reduzo a pena cominada de 1/2, tornando-a definitiva em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal. Considerada a pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 1º, c, e § 3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 95/97 para condenar o réu JOÃO MÁRCIO SOUZA CRUZ OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal. Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §§ e incisos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta, por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade tal como regulamentada pelo juízo da execução criminal e mais dez dias-multa, totalizando pois 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal.

Nesse sentido: "Atendidos os requisitos

de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado." (HC111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, "Informativo/STF nº 672"). Faculto ao réu eventual recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para cumprimento do quanto disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso pelas partes e réu, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se guia de recolhimento e ofícios de estilo, arquivando-se. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas pelo Sistema OneDrive:
(copiar e colar no navegador)

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjssp_jus_br/EogCxmgMH-hArExy6H1udgsBSfUOhlq0WKYipbXR0k6Wqg?e=VeAMbB